

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

INFRACCIÓN A LOS DEBERES FUNCIONALES DE UN SERVIDOR PÚBLICO/ Diferencias entre el derecho penal y el disciplinario/ figuras de coautoría y complicidad.

Frente al anterior alegato debe decir este despacho ad-quem que, dentro del derecho disciplinario, al investigarse infracciones a los deberes funcionales, las conductas deben ser valoradas individualmente, tal como lo ha subrayado pacíficamente la jurisprudencia¹, por consiguiente, al momento de analizar la averiguación disciplinaria, se hace por cada uno de los individuos.

vinculados a la instrucción, esto es de manera individual y por separado, atendiendo a los elementos de hecho y de derecho de cada caso en particular y concreto, por lo que la decisión que adopte la Administración en estos casos solo puede afectar única y exclusivamente a quien es el titular del respectivo deber funcional cuestionado en sede disciplinaria.

Esta es una de las razones por las cuales las figuras de la coautoría y la complicidad no son de recibo en la doctrina y jurisprudencia disciplinaria, muestra de ello es el contenido de la Sentencia C- 098 de 2003, la cual señaló:

*“Sabido es que el derecho penal y el derecho disciplinario son consecuencia de la facultad punitiva del Estado, y en cuanto tal, ostentan elementos comunes. Sin embargo, entre derecho penal y derecho disciplinario existen importantes diferencias que frustran cualquier conato de confusión, y que, por el contrario, ponen de manifiesto sus respectivas identidades. Una de las diferencias cardinales estriba en las modalidades de la participación quebrantadora, toda vez que mientras en la esfera del estatuto penal caben hipótesis como la del coautor, determinador y el cómplice, por contraste, **en el campo del estatuto disciplinario las conductas suelen ser individuales**. Así, por ejemplo, a nadie se le podría acusar como cómplice de que un servidor público llegue tarde a su oficina de trabajo”. (Subrayas del despacho).*

¹ Corte Constitucional Sentencia C401-2013 y Sentencia C- 098 de 2003.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

Así las cosas, cuando la Ley 734 de 2002, en su artículo 23 establece la denominación de las conductas disciplinables por parte de los servidores públicos², debe interpretarse en la necesidad por tanto de controvertir las decisiones que perjudican al directo inconforme, sin que pueda llegar más allá la interpretación de esta norma o hacerla extensiva a otros eventos; esto es que sobre la aplicación del derecho disciplinario, los deberes funcionales son de cumplimiento individual y es claro que quien sufre el agravio y está legitimado para recurrir es quien es objeto del reproche de la conducta específica y no quien por una u otra razón cuestiona otros comportamientos atados a su propio deber funcional, en tal sentido, no sirve de excusa para relevar la responsabilidad disciplinaria, aducir el error o la falta, en la conducta omisiva, incumplidora o extra limitante de otro servidor público, por cuanto como se itera, las conductas de los funcionarios públicos obedecen estrictamente a la Ley y al reglamento³, y por tanto su resquebrajamiento funcional es de orden personal, e intransferible.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 23 – 27.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-053
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 009 del 6 de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho de segunda instancia a resolver el recurso de apelación interpuesto por la abogada de oficio del sujeto procesal XXX, contra la decisión del pasado diecisiete (17) de febrero de 2016, por medio de la cual la subdirección técnica de investigaciones disciplinarias de esta

² Ley 734 de 2002 Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

³ CN. ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

UAE- Agencia ITRC, profirió fallo sancionatorio de primera instancia dentro del proceso administrativo disciplinario No.1704-01- 2013-0053.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Al presente juicio y luego de adelantarse la correspondiente etapa instructiva⁴, fue llamado a responder disciplinariamente mediante auto de cargos el funcionario de la UAE-DIAN, XXX,⁵ por la presunta incursión en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 del CDU, referente a *“realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, en complementación normativa con el artículo 286 del código penal Colombiano, referente al punible de falsedad ideológica en documento público*⁶.

2.- A la anterior imputación arribo el despacho a-quo, en síntesis, con base en los siguientes hechos instruidos:

⁴ Ver fol.60-61 Cn 1 auto de indagación preliminar y a folios 77-79; auto apertura de investigación disciplinaria a fol. 131-133 Cn 1; auto pliego de cargos a fol. 1213-1260.

⁵ XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, funcionario activo de la planta de personal de la U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DI AN, cuya época de ingreso data del 03 de diciembre de 2001; teniéndose entonces, para la época de los hechos objeto de estudio, ejercía como ejecutor II de gestión y servicio a los procesos misionales; vinculado a la precitada Entidad en la División de Gestión de Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, bajo el cargo nominal de Analista li Nivel: 202 Grado: 02

⁶ Ley 599 de 2000 Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

2.1.- Que la actuación disciplinaria tuvo su origen en el oficio No.1-03-247-142 del 22 de octubre de 2012, suscrito por el entonces Jefe de la División de Gestión de Control Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, XXX⁷, como medio de información para dar cuenta de presuntas irregularidades detectadas en esa dependencia durante los días 15 y 16 de octubre de 2012, referentes a trámites en el diligenciamiento de las actas de Inmovilización No.1241 y su consecuente acta de aprehensión No. 1664; acta de Inmovilización No.715 de fecha 2 de mayo de 2012 y su consecuente acta de aprehensión No. 1563, calendada el día 1 de mayo de 2012; acta de Inmovilización No.1297 y su consecuente acta de aprehensión No. 1573, ambas datadas el día 5 de agosto de 2012; acta de Inmovilización No.1378 y su consecuente acta de aprehensión No.1572, acta de inmovilización No.1285 de 3 de agosto de 2012 y su consecuente acta aclaratoria de aprehensión No.1562, de 2 de agosto de 2012, todas estas actas al parecer realizados por el funcionario XXX, sin que las fechas de las actas correspondan en los registros informáticos generados por el aplicativo viajeros, con el día cierto de realización de las diligencias y operaciones aduaneras de inmovilización y aprehensión respectivos.

3.- Descorridos los cargos por la defensa de oficio del encartado⁸, resueltas y practicadas las solicitudes probatorias propuestas⁹, escuchado en versión libre y espontánea al expedientado¹⁰ y descorridos los alegatos de conclusión, se profirió por la sub dirección disciplinaria ITRC, fallo de primera instancia sancionatorio¹¹ en los siguientes términos:

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante resolución No.17317-00005 del pasado diecisiete (17) de febrero de 2016¹² el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de esta Agencia ITRC, profirió fallo sancionador de primera instancia en el cual resumió en algunos párrafos los hechos objeto de investigación, los cargos formulados y los argumentos defensivos planteados por los sujetos procesales a lo largo del juicio, como de los alegatos de conclusión. De la misma manera se

⁷ Ver fol. 2 a 4 Cn 1.

⁸ Ver folio folios 681 a 686 Cn 3.

⁹ Ver fol. (folios 590 a 600).

¹⁰ Ver folios 91- 93 Cn 1.

¹¹ Ver fol.629-661 Cn 4.

¹² Ver folios 629-661 Cn 4.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

resumieron y evaluaron conjuntamente la totalidad de las pruebas recaudadas a lo largo de la actuación.

Inmediatamente después, la primera instancia inició su exposición de motivos citando la normatividad que le atribuye competencia para fallar el sub examine; a renglón seguido nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación integral probatoria.

Al respecto consideró el fallador de primera instancia, que con base en el análisis probatorio decretado y practicado legal y oportunamente en el plenario, tanto en la etapa de instrucción como en el juicio, la imputación que se formuló al investigado dentro de los cargos, constituyó una imputación diáfana y concreta, de suerte que el disciplinado contó con todas las posibilidades procesales de ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de la misma, para proceder a decidir como en derecho correspondía.

Continuando con la motivación del fallo, referente a la valoración probatoria, estimo el a-quo que se encontraba probada en grado de certeza la materialización de la conducta típica e ilícitamente sustancial endilgada en el pliego de cargos¹³ al funcionario XXX, referente al punible de falsedad ideológica, porque en ejercicio de sus funciones, extendió y registró en el software del aplicativo viajeros de la Dirección Seccional de aduanas Bogotá, fechas diferentes al día cierto de realización de las diferentes diligencias de inmovilización y aprehensión de los procedimientos aduaneros a su cargo.

En tal sentido considero el despacho de primera instancia que efectivamente la conducta endilgada al procesado, se adecuaba a la descripción típica del artículo 48 núm.1 del CDU arriba referido en complementación normativa con el artículo 286 del Código Penal referente al punible de falsedad ideológica en documento público, toda vez que quedó demostrado en grado de certeza en el expediente, que el señor XXX en su calidad de servidor público de la División de Gestión de Viajeros, de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, en cumplimiento de sus funciones, extendió y registró en el software de la dependencia, aplicativo denominado "Viajeros", fechas diferentes al día cierto de realización de las diferentes diligencias de inmovilización y aprehensión a su cargo, respecto de las siguientes actas:

¹³ Ver folio 365-372 Cn 2.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

1. Acta de Inmovilización No. 1241 y su consecuente Acta de Aprehensión No. 1664, ambas datadas el día veintitrés (23) de octubre de 2011, así como el sello estampado en dichas diligencias con ese mismo día, se tiene que al parecer dicha anotación no corresponde, habida cuenta que el registro consecutivo generado por el aplicativo denominado "Viajeros", difiere de tales consignas, este asiento informático que se entiende como fecha de realización de la actuación en el sistema, se remonta al día diez (10) del mismo mes y año 2012.
2. Acta de Inmovilización No. 715 de fecha 2 de mayo de 2012 y su consecuente Acta de Aprehensión No. 1563, calendada el día 1 de mayo de 2012, así como el sello estampado en dichas diligencias con este último día, se tiene que al parecer dicha anotación no corresponde, habida cuenta que el registro consecutivo generado por el aplicativo denominado "Viajeros", difiere de tales consignas, este asiento informático que se entiende como fecha de realización de la actuación en el sistema, se remonta al día veinticuatro (24) de septiembre de 2012. Aunado a lo anterior, aparece registro de solicitud del documento COMEX, el día 1 de mayo de 2012, cuando al parecer, éste se solicitó el día 8 de octubre de 2012.
3. Acta de Inmovilización No. 1297 y su consecuente Acta de Aprehensión No. 1573, ambas datadas el día 5 de agosto de 2012, así como el sello estampado en dichas diligencias con este día, se tiene que al parecer dicha anotación no corresponde, habida cuenta que el registro consecutivo generado por el aplicativo denominado "Viajeros", difiere de tales consignas. En otras palabras, este asiento informático que se entiende como fecha de realización de la actuación en el sistema, se remonta al día veinticuatro (24) de septiembre de 2012. Aunado a lo anterior, aparece registro de solicitud del documento COMEX, el día 5 de agosto de 2012, cuando al parecer, éste se solicitó el día 8 de octubre de 2012.
4. Acta de Inmovilización No. 1378 y su consecuente Acta de Aprehensión No. 1572, ambas datadas el día 22 de agosto de 2012 y el primero de estos documentos fechado también con el día 23 del mismo mes y año, así como el sello estampado en dichas diligencias con este último día, se tiene que al parecer dicha anotación no corresponde, habida cuenta que el registro consecutivo generado por el aplicativo

denominado "Viajeros", difiere de tales consignas, este asiento informático que se entiende como fecha de realización de la actuación en el sistema, se remonta al día veinticuatro (24) de septiembre de 2012. Aunado a lo anterior, aparece registro de solicitud del documento COMEX, el día 23 de agosto de 2012, cuando al parecer, éste se solicitó el día 8 de octubre de 2012.

5. Acta de Inmovilización No. 1285 de 3 de agosto de 2012 y su consecuente Acta Aclaratoria de Aprehensión No. 1562, de 2 de agosto de 2012, sin que antes de la elaboración de esta acta exista previamente la de Aprehensión, así como el sello estampado en dichas diligencias con este último día, se tiene que al parecer dicha anotación no corresponde, habida cuenta que el registro consecutivo generado por el aplicativo denominado "Viajeros", difiere de tales consignas, este asiento informático se entiende como fecha de realización de la actuación en el sistema, se remonta al día veintidós (22) de septiembre de 2012. Aunado a lo anterior, aparece registro de solicitud del documento COMEX, el día 12 de agosto de 2012, cuando al parecer, éste se solicitó el día 8 de octubre de 2012.

Continuando el despacho a-quo con la motivación del fallo, argumentó el cabal cumplimiento del requisito de la ilicitud sustancial satisfecho, al expresar que la conducta imputada y sancionada al procesado vulneró sus deberes funcionales sin justificación alguna, pues en su condición de servidor público debía actuar bajo postulados de moralidad pública, fe pública, diligencia, eficiencia, eficacia, responsabilidad y cuidado en sus actuaciones, es decir a partir de normas de carácter y rango ético y moral elevados a categoría de deberes funcionales de su ejercicio, tal como lo establece la ley disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto, al asumir sus cargos los disciplinados, se comprometieron a cumplir con fidelidad, cabalidad y respeto sus deberes funcionales, legales y Constitucionales; situación que considero el despacho instructor que en el sub examine no se cumplió en estrictez, sino que por el contrario el expedientado mancilló los principios enunciados de la función pública a los que estaba obligado a acatar, sin justificación alguna.

Con relación al requisito estructural normativo de la culpabilidad de la falta, mantuvo el fallador de primera instancia su posición esbozada en el auto de cargos, al considerar que la falta objeto de sanción debía ser imputada a título de dolo, por cuanto consideró que el funcionario era plenamente capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento, dada su trayectoria en la

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

entidad, la comprensión de las repercusiones legales de su actuar y el contenido de las normas que regulan la materia, completamente conocidas por el disciplinado, según el mismo lo aceptó en sus injuradas.

Por lo anterior concluyo el despacho a-quo que no existía duda en el conocimiento, intencionalidad y ánimo del señor XXX, de registrar las mantadas actas en el aplicativo viajero, con datos apócrifos sobre las fechas de las actas, por las que se le llamo a responder disciplinariamente.

En el acápite subsiguiente, titulado contestación a los argumentos de defensa, el fallador de primer grado hizo énfasis en que no le asiste razón a la defensa, en la pretensión de justificar la conducta del investigado, porque está demostrado que el diligenciamiento del formato de las actas de inmovilización y de aprehensión no era complejo, ni en su incorporación, ni en su motivación, menos en la inscripción de las fechas ciertas de las operaciones aduaneras que se debían consignar, esto es precisamente, el momento en el cual efectivamente se daba por aprehendida la mercancía, luego de la solicitud del número COMEX.

Por lo anterior y en lo concerniente a la calificación de la falta, el despacho a quo mantuvo la posición previamente asumida en el auto de cargos, en consecuencia, califico el elemento subjetivo de la conducta imputada disciplinariamente al funcionario XXX como dolosa, al hallarla enmarcada en los preceptos normativos del artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en complementación normativa con el artículo 286 del CP referente al punible de falsedad ideológica en documento público.

En el proceso de dosificación de la sanción, atendiendo a la calificación concreta como gravísima a título de dolo imputada al disciplinado, consideró el despacho de primera instancia viable la imposición de la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de diez (10) años, al señor XXX, teniendo en cuenta para la graduación de la sanción los criterios normativos en su favor del artículo 47 del CDU.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

El fallo de primera instancia proferido por la subdirección disciplinaria de esta UAE-Agencia ITRC mediante resolución No.17317-00005 del 17 de febrero de 2016, fue notificado a los sujetos procesales, de manera personal a la defensa oficiosa el día 26 de febrero de 2016¹⁴, y al señor XXX, por edicto del día 9 de marzo de 2016¹⁵; en consecuencia, impugna la providencia notificada, la defensa de oficio con escrito del 2 de marzo de 2016¹⁶, esto es en términos; recurso que no se advierte entonces haya sido formulado por el sujeto procesal XXX.

Así las cosas, solo se estudiará y ocupará este despacho ad-quem del recurso de apelación impetrado en términos por la defensa oficiosa del señor XXX, quien goza de legitimidad en la causa para sustentar la impugnación.

Al respecto se tiene que la defensa denomina su escrito como apelación parcial al fallo de primera instancia, y lo cierne sobre la pretensión de rebajar a la menor pena aplicable a su defendido, teniendo en cuenta para ello los criterios favorables del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, citando para ello que sean revisados en favor de su prohijado los numerales 3, 4, 5, del articulado, referentes al grado de perturbación del servicio con la comisión de la falta, a la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución y a la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado; lo mismo refiere la defensa sobre el literal h del artículo 47 ídem, esto es, a la ausencia de afectación a derechos fundamentales con la comisión de la falta disciplinaria (sic).

Frente al fondo del asunto, manifestó la defensa que las actuaciones del disciplinado debieron ser revisadas, autorizadas y avaladas por su superior jerárquico, y que por tanto dichas actuaciones bien pudieron haber sido corregidas al momento que el superior jerárquico advirtió las irregularidades, solución que no fuera atendida por el jefe de área pese a haber sido planteada por el disciplinado, según lo señalo en su injurada, lo que en consideración de la defensa ocasiono las mentadas irregularidades de su prohijado.

En síntesis, estos fueron los planteamientos de defensa por los cuales la defensa de oficio del expedientado XXX, solicitó la rebaja en la sanción impuesta.

¹⁴ Ver fol. 665 Cn. 4.

¹⁵ Ver fol. 672 Cn. 4.

¹⁶ Ver fol. 666 Cn 4.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Previo a dar inicio a las consideraciones de instancia, es importante precisar que de conformidad con las prerrogativas legales consagradas en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, *“...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindibles a la impugnación...”* (Sic).

Esta segunda instancia para determinar si le asiste razón o no a la recurrente, indicara cual es la situación probatoria del expediente respecto del disciplinado XXX, y extractara de ella las conclusiones a las que allá lugar, dando respuesta específica a los planteamientos invocados por su defensa.

Sobre el particular se tiene que la defensa oficiosa plantea la rebaja en la sanción impuesta al funcionario XXX, con base en que se consideren en su favor, las prerrogativas en la pena establecidas en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, referentes a los numerales 3, 4 y 5 de la mentada norma; con el objeto de imponer la menor sanción posible al procesado.

Así mismo, establece este despacho ad-quem, que la pretensión de la defensa fue en efecto valorada en el fallo de primera instancia, el cual en tal sentido impuso al funcionario XXX, la menor sanción preceptuada dentro del rango de sanciones previstas para las faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título doloso, según las voces del artículo 44 núm. 1 del CDU, norma que sobre el particular establece:

Ley 734 de 2002 Artículo 44.

“...Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima (sic).”

Sobre el quantum de la inhabilidad general para las faltas disciplinarias con destitución, establece el artículo 46 de la misma obra normativa:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

"...Artículo 46. Límites de las sanciones. La inhabilidad general será de diez (10) a veinte (20) años; (sic)."

Por otra parte, se establece del fallo atacado que frente a los criterios facticos como normativos que se tuvieron en cuenta para la determinación de la sanción a imponer en el sub examine, se dijo en el ítem, denominado "FUNDAMENTOS Y CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN":

"...Como quedó en el presente proceso, el disciplinado XXX, es responsable de cometer la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en incurrir en una conducta objetivamente establecida por la ley como delito a título de dolo, como lo es la falsedad ideológica en documento público. En consecuencia, configurados los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad del involucrado, es menester proceder a determinar la sanción a imponer; por lo que consonante con la norma disciplinaria el fallador de instancia procederá así: El artículo 4o de la ley 734 de 2002, consagra el principio de legalidad al cual debe ajustarse toda actuación disciplinaria y dentro de éste, también se consagra el principio de legalidad de la sanción, debiendo imponerse sólo la que está contemplada en la ley, conforme a la conducta o falta disciplinaria, por la cual se encontró responsable al servidor público.

A la par, el legislador estimó, conforme al Artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que la sanción a imponer cuando se trata de faltas gravísimas cometidas a título de dolo, como es nuestro caso, será la de destitución e inhabilidad general, esta última atendiendo lo dispuesto en el artículo 46 ibídem, será de 10 a 20 años, Las regulaciones en comento dicen: "ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima "ARTÍCULO 46. LÍMITE DE LAS SANCIONES. La inhabilidad general será de diez a veinte años...". Aclarado lo anterior, al tenor del artículo 47 de la Ley disciplinaria, los siguientes son los criterios legales de tasación de la sanción a imponer: "ARTÍCULO 47. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. 1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

"a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;" Según el reporte SIRI de Procuraduría General de la Nación, consultado el día 14 de enero de 2016, el disciplinado no tiene anotaciones correspondientes a antecedentes disciplinarios. De conformidad con este criterio, aquel funcionario que reincida en la violación del régimen disciplinario, deberá ser sancionado en una segunda o tercera oportunidad con mayor rigor y escarmiento, con el objetivo de cumplir con los fines propuestos de la sanción disciplinaria de prevención general positiva y correccional. Este criterio no puede tenerse como un dispositivo agravante de la conducta disciplinable del investigado, contrario sensu, opera a su favor.

"b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;" Frente a este criterio, debe decirse que el Despacho no tiene elementos para emitir un juicio de valor respecto del desempeño del funcionario,

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

por ello, este criterio se tendrá en cuenta a favor del señor disciplinado, como quiera que no está acreditado en el proceso, que el rendimiento del funcionario haya sido deficiente.

"c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;" Aunque se hizo breve mención, hay que señalar que en el caso sub examine, el investigado asumió su defensa sin involucrar a terceras personas. Así las cosas, este criterio no afecta negativamente la dosificación de la sanción, ya que el espíritu de la norma pretende castigar con mayor severidad a aquellos sujetos procesales que asumen su defensa con acusaciones temerarias contra terceros.

"d) La confesión de la falta antes de la formulación de caraos:" Este criterio no aplica para el caso concreto.

"e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;" La norma prevé un comportamiento positivo del agente tendiente a remediar los efectos de la infracción. De suerte tal, que en aquellos eventos en los cuales se presenta una actitud resarcitoria o proclive a enmendar los efectos de la infracción disciplinaria, el legislador ha otorgado la posibilidad de alivianar el quantum de la sanción. En el caso concreto, no se verificó un comportamiento del señor XXX y ello es así, dado que, por la naturaleza de la conducta reprochada, difícilmente podía extenderse una actividad resarcitoria de su parte. En síntesis, este criterio no está llamado a agravar la conducta del disciplinado.

"f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;"

g) El grave daño social de la conducta;

h) La afectación a derechos fundamentales;

i) El conocimiento de la ilicitud;"

"j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad." (...)"

De conformidad con los criterios analizados en precedencia, los cuales son los que están establecidos como puede leerse en el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, este fallador de instancia estima, en ejercicio del principio de la proporcionalidad, que debe imponerse al señor XXX, es sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general de diez (10) años, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive del presente proveído.

Como se observa de una simple lectura de las anteriores consideraciones, el despacho a-quó, estudio uno a uno los criterios normativos establecidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 en favor del expedientado, para la dosificación de la sanción a imponer en las faltas gravísimas a título doloso, concluyendo que, sobre el particular y en virtud del principio de proporcionalidad de las faltas y las sanciones, se le debía aplicar la menor inhabilidad general al señor XXX, esto es la destitución e inhabilidad general por el término de diez años, en el entendido que la mayor sanción como se establece de la norma en estudio, concierne a inhabilidad general por el término de veinte años.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

En tal sentido no prospera el cargo sobre la graduación o rebaja de la sanción impuesta, por encontrarse ajustada a derecho la dosificación de la sanción referente a la inhabilidad mínima para las faltas disciplinarias gravísimas dolosas, impuesta en el sub examine al disciplinado, por el despacho de primera instancia.

Frente al alegato de que las actuaciones del disciplinado debieron ser revisadas, autorizadas y avaladas por su superior jerárquico, y que por tanto dichas actuaciones bien pudieron haber sido corregidas al momento que el superior jerárquico advirtió las irregularidades, solución que no fuera atendida por el jefe de área pese a haber sido planteada tal solución por el disciplinado, según lo señaló en su injurada, lo que en consideración de la defensa ocasiono las mentadas irregularidades de su prohijado.

Frente al anterior alegato debe decir este despacho ad-quem que, dentro del derecho disciplinario, al investigarse infracciones a los deberes funcionales, las conductas deben ser valoradas individualmente, tal como lo ha subrayado pacíficamente la jurisprudencia¹⁷, por consiguiente, al momento de analizar la averiguación disciplinaria, se hace por cada uno de los individuos.

vinculados a la instrucción, esto es de manera individual y por separado, atendiendo a los elementos de hecho y de derecho de cada caso en particular y concreto, por lo que la decisión que adopte la Administración en estos casos solo puede afectar única y exclusivamente a quien es el titular del respectivo deber funcional cuestionado en sede disciplinaria.

Esta es una de las razones por las cuales las figuras de la coautoría y la complicidad no son de recibo en la doctrina y jurisprudencia disciplinaria, muestra de ello es el contenido de la Sentencia C- 098 de 2003, la cual señaló:

“Sabido es que el derecho penal y el derecho disciplinario son consecuencia de la facultad punitiva del Estado, y en cuanto tal, ostentan elementos comunes. Sin embargo, entre derecho penal y derecho disciplinario existen importantes diferencias que frustran cualquier conato de confusión, y que, por el contrario, ponen de manifiesto sus respectivas identidades. Una de las diferencias cardinales estriba en las modalidades de la participación quebrantadora, toda vez que mientras en la esfera del estatuto penal caben

¹⁷ Corte Constitucional Sentencia C401-2013 y Sentencia C- 098 de 2003.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

hipótesis como la del coautor, determinador y el cómplice, por contraste, **en el campo del estatuto disciplinario las conductas suelen ser individuales**. Así, por ejemplo, a nadie se le podría acusar como cómplice de que un servidor público llegue tarde a su oficina de trabajo". (Subrayas del despacho).

Así las cosas, cuando la Ley 734 de 2002, en su artículo 23 establece la denominación de las conductas disciplinables por parte de los servidores públicos¹⁸, debe interpretarse en la necesidad por tanto de controvertir las decisiones que perjudican al directo inconforme, sin que pueda llegar más allá la interpretación de esta norma o hacerla extensiva a otros eventos; esto es que sobre la aplicación del derecho disciplinario, los deberes funcionales son de cumplimiento individual y es claro que quien sufre el agravio y está legitimado para recurrir es quien es objeto del reproche de la conducta específica y no quien por una u otra razón cuestiona otros comportamientos atados a su propio deber funcional, en tal sentido, no sirve de excusa para relevar la responsabilidad disciplinaria, aducir el error o la falta, en la conducta omisiva, incumplidora o extra limitante de otro servidor público, por cuanto como se itera, las conductas de los funcionarios públicos obedecen estrictamente a la Ley y al reglamento¹⁹, y por tanto su resquebrajamiento funcional es de orden personal, e intransferible.

Sin embargo, a la anterior consideración, debe precisarse por este despacho ad-quem que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que las labores de seguimiento, control y vigilancia de los jefes, coordinadores, o directivos del Estado en las labores o funciones encomendadas en sus subalternos y con relación a sus funciones o cargos, no se suplen por la mera orden, mandato, delegación o encargo de la función o labor encomendada, y por tanto desentendiéndose del desarrollo o ejecución de la misma, sino que por el contrario, debe ejercerse un constante seguimiento y control, que sobre tales ordenes, mandatos o funciones se imparta por la autoridad que la profiere, so pena de responder quien da la orden a los regímenes

¹⁸ Ley 734 de 2002 Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

¹⁹ CN. ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

sancionadores del estado, a condición de que no lo haya provocado dolosamente, o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida; en tal sentido ha dicho la jurisprudencia:

*“Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esto implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido de una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición naturalmente **de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida**”* (Sentencia de única instancia del 21 de marzo de 2002, M. P. Carlos Eduardo Mejía Escobar, Radicación No. 14.124). (Subrayas fuera del texto).

Así también la Honorable Corte Constitucional ha establecido que la labor del delegatario no exonera al delegante de la responsabilidad que sobre el recaiga:

*“El principio de coordinación Administrativa implica que dada la existencia de una función administrativa específica que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, la autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de la orientación vigilancia y control de sus subalternos. De donde el delegante siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones de vigilancia control y orientación del delegatario en lo que concierne al ejercicio de la función delegada, por lo cual cuando la norma acusada prescribe que nunca quedara exonerado de dicha responsabilidad, simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por el artículo 211 de la Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática. La función de vigilancia orientación y control de la que no se desprende el delegante por el hecho de la delegación implica que, respecto de ella, **siempre conserve una responsabilidad subjetiva, como justamente lo provee la disposición acusada, responsabilidad por la que el servidor público responde individualmente por sus acciones omisión y decisiones.**”* (Sentencia C 693- del 9 de julio de 2008 M.P: MARCO GERARDO MONROY CABRA). (Subrayas fuera del texto).

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

En tal sentido y observados con detenimiento los elementos facticos propios del sub examine, considera este juzgador ad-quem, que si bien el argumento de defensa referente a que la conducta del expedientado estuvo amparada por el auspicio o conocimiento del jefe directo del señor XXX y que en tal sentido resulta irresponsable para la administración su conducta; resulta ser a todas luces un argumento divorciado del ordenamiento jurídico, como se establece de la jurisprudencia y las consideraciones ut-supra; sin embargo, resultará propio compulsar las respectivas copias de la presente decisión a la Sub Dirección de control interno disciplinario de la UAE- DIAN, para que dicha autoridad determine si en efecto existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria por incumplimiento, omisión o extralimitación funcional, de los jefes o coordinadores del señor XXX, en la conducta, o consustancial a aquella, por la que se le declaró responsable en el plenario.

Basten hasta aquí las consideraciones ut supra, para rechazar los argumentos de sustentación de la apelación presentados por la defensa recurrente, solo resta afirmar haciendo eco del análisis probatorio realizado por el operador disciplinario de primer grado, que el expedientado XXX, incurrió en la falta disciplinaria objeto de censura, razón por la cual deberá responder disciplinariamente por dicho comportamiento, tal como se expresará en la parte resolutive de esta providencia, al confirmar en su totalidad el fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el procesado XXX, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, **CONFIRMAR EN SU TOTALIDAD** el fallo sancionatorio proferido por el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de la UAE Agencia ITRC, mediante resolución número 17317-00005 del diecisiete (17) de febrero de 2016 dentro del expediente disciplinario 1704-01-2013-053.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-00053

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** la sanción disciplinaria ante la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

SEPTIMO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y parágrafo del artículo 172 de la ley 734 de 2002.

OCTAVO. REMITIR copia de la presente decisión a la Sub Dirección de control interno disciplinario de la UAE-DIAN, para que dicha autoridad, en el ámbito de sus competencias, determinen lo que sobre el particular corresponda.

NOVENO: Ejecutoriada esta decisión y libradas las comunicaciones de rigor, ARCHIVAR el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE

Directora General

Proyectó: Dr. Julian Andres Garcia Novoa
Aprobó: Dr. (a) Carmen Maritza González M. – Directora General.